

1503126-96.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas. 9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1503126-96.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503126-96.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VICTOR VIANA MATIAS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

VICTOR VIANA MATIAS, qualificado no autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque em 07 de dezembro de 2021, às 15:30 horas, na Rua Serra Lua, Mirante do Arujá, nesta cidade, trazia consigo para fins de tráfico quatro embalagens contendo lança-perfume, 12 porções de crack (0,83 gramas - massa líquida), 22 porções de maconha (70,22 gramas - massa líquida) 03 porções de cocaína (0,72 gramas - massa líquida), e mais 58 porções de cocaína (2,0 gramas - massa líquida), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narra a acusação que o acusado na data dos fatos trazia consigo uma sacola contendo drogas, estando numa escada que liga a Rua Serra do Gil e Rua Serra da Lua. Guardas civis receberam denúncia de tráfico de drogas e se dirigiram ao local, sendo visualizado o acusado. Ao perceber a aproximação dos guardas civis, o acusado tentou fugir, mas foi abordado num terreno baldio, oportunidade em que a sacola contendo as drogas foi localizada.

Auto de prisão em flagrante (fl. 01). Boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07). Laudo de constatação (fls. 26/32).

Em audiência de custódia foi mantida a prisão do acusado (fls. 39/42).

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar às fls. 89/90.

A denúncia foi recebida em 02/05/2022, às fls. 98/99.

Laudo pericial definitivo (fls. 104/106).

Em audiência foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado (fls. 123/124 e 132/135).

Na fase de debates, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela improcedência do pedido acusatório, diante da ilicitude da prova, uma vez que guardas civis municipais não podem realizar policiamento ostensivo e realizar buscas pessoais. Afirmou que a ação policial não observou preceito Processual Penal e Constitucional não podendo a Guarda Civil Metropolitana agir como Policial Militar na repressão de crimes. Afirmou que o delito de tráfico é permanente, mas inexiste efetiva situação de flagrante, não sendo visualizada venda de drogas a terceiro.

A defesa do réu em alegações finais orais acompanhou a manifestação do Ministério Público, requerendo a absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal penal é improcedente.

A materialidade do delito de tráfico não está devidamente comprovada, uma vez que houve, como bem altercou o órgão acusador, atuação ilegal da Guarda Civil Metropolitana, o que acarreta a ilicitude de toda a prova colhida nos autos, em que pese tenha o réu confessado o delito e haja indícios de autoria.

Passo à análise da prova oral colhida no feito:

A testemunha André de Almeida Ribeiro, guarda civil municipal, declarou que no dia estavam em patrulhamento pelo bairro e houve denúncia de tráfico de drogas no local. O acusado saiu correndo quando avistou a viatura e conseguiram ver a roupa dele, que era blusa azul com vermelho e bermuda lilás. Encontraram o acusado num terreno baldio, com sacola contendo maconha, crack e lança-perfume. Disse que houve denúncia irradiada pelo Secom. As drogas estavam numa sacola preta na mão do acusado.

O acusado Victor Viana Matias declarou em interrogatório judicial que tem 19 anos, trabalhava com lava rápido e é tatuador. Ganhava R\$ 150,00 em diárias, tendo renda mensal em torno de R\$ 400,00 no lava rápido e com tatuagens ganhava em torno de uns R\$ 600,00 por mês. Estudou até o 1º ano. É solteiro e não tem filhos. Não foi processado antes, somente quando era menor de idade. Em relação aos fatos, declarou que as drogas estavam na sua posse. Contou que um colega lhe perguntou se queria ganhar dinheiro, aceitando a proposta. Foi até onde ele chamou e esperou um tempo. Viu a viatura da GCM vindo. Ia ganhar R\$ 200,00 para vender a droga até às 18:00 horas. Disse que sua família tem condições e quer uma oportunidade. Está arrependido.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O acusado confessou o cometimento do delito, afirmando que aceitou oferta de terceiro para venda de drogas, e ganharia para tanto R\$ 200,00.

Um guarda civil metropolitano foi ouvido como testemunha e narrou que receberam denúncia de tráfico no local, avistaram o acusado, que teria corrido, e após, conseguiram localizar o réu num matagal, quando localizaram com ele sacola contendo drogas.

O laudo toxicológico de fls. 104/106 confirma a natureza entorpecente das drogas encontradas.

Pois bem.

Deve ser acolhido o pleito do Ministério Público e da defesa, absolvendo-se o acusado.

Deveras, como se extrai dos autos, guardas civis municipais realizaram a abordagem do acusado.

Primeiramente, aponta-se que no caso dos autos, defronta-se este juízo com a atuação ilegal, já que fora das atribuições legais e constitucionais, da Guarda Civil Metropolitana, o que acarreta que toda a prova é derivada de atuação ilegal da Guarda Civil Metropolitana de Arujá.

Observo que a finalidade epistêmica do processo penal é a busca da verdade, ainda

que de forma aproximada, por meio de reconstrução fática que leve a superação do postulado da presunção de inocência e permita a imposição legítima de uma sanção penal. Entretanto, este objetivo teleológico deve ser buscado com respeito as regras legais e constitucionais de produção e valoração das provas.

Assim, não é possível, dentro de um processo penal de fundamento democrático, a valoração da prova dissociada da ideia de legalidade. A legalidade da prova é pressuposto do juízo de mérito. O processo não é um fim em si mesmo e a verdade não pode ser buscada a qualquer custo, ainda mais havendo sacrifício de direito individual.

Antes de qualquer valoração racional é sempre necessário o escrutínio da fonte legal da prova.

Nesse sentido:

“assim, no Brasil, os códigos processuais, civil e penal, dispõem justamente acerca da validade da prova da verdade, que deverá seguir um trâmite que não cause surpresa às partes (livre acesso), que amplie sua participação no discurso relacionado ao seu enunciado (contraditório), que seja adequada e idônea ao fato que se quer provar e que não seja obtida por meios ilícitos. A busca da verdade não é, assim, orientada para a obtenção da verdade substancial, mas apenas da verdade provavelmente admitida. Não vigora mais, assim, no processo a busca da verdade real. Até porque, como já se disse, não existe essa suposta verdade real. Seria uma pretensão audaciosa do direito entender que o juízo possa fazê-lo unicamente pelos instrumentos legais.” (TAVARES, Juarez, CASARA, Rubens. Prova e verdade. 1ª ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020, p. 147).

O Código de Processo Penal, saliente-se, adotou o sistema do livre convencimento objetivo motivado do juiz, pelo qual incumbe ao magistrado formar sua convicção a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que fundamentadamente.

Em outras palavras, não é lícito ao julgador formar sua convicção e, por conseguinte, proferir sentença condenatória com base em elementos colhidos ao arrepio de direitos individuais e de regras legais.

O material probatório levado à análise judicial deve se revestir de legalidade, o que não se verifica no presente caso, inclusive como apontou o Ministério Público em alegação finais.

O réu, em juízo, confessou o delito, contudo, tal confissão não tem o condão de trazer legalidade ou rechaçar nulidade advinda da atuação indevida da Guarda Civil Metropolitana de Arujá.

Isso porque extrai-se dos autos que a prova produzida em juízo tem uma fonte: diligência de polícia preventiva realizada pela Guarda Civil.

O art. 144, parágrafo 8º da CF/88 dispõe que “os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.”.

O Município de Arujá, atendendo ao comando constitucional, constituiu, de fato, a Guarda Civil visando a preservação de seus bens, serviços e instalações. Trata-se, assim, de verdadeira guarda patrimonial.

A mesma Constituição, por sua vez, no art. 144, parágrafo 5º, asseverou que cabe às polícias militares a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

Portanto, por uma simples leitura dos dispositivos verifica-se que não cabe à Guarda Civil a atividade fim de polícia preventiva, como, no caso em tela, de abordagem de sujeito suspeito da prática de infração penal.

Em outras palavras, a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, somente pode ser realizada e considerar-se, destarte, legal cumprindo-se dois pressupostos: a) que haja fundada suspeita de ocultação de objetos ilícitos; b) que a autoridade tenha competência legal para fazê-lo.

A estes servidores da municipalidade, frise-se, não são acometidas as funções de polícia judiciária ou repressiva e, assim, não estão legitimados a coletarem provas voltadas às futuras utilizações em processo penal ou a realizarem prisões nas quais não haja clara evidência de flagrante, em ambas situações com violação direitos fundamentais.

Nesse sentido, acerca da ausência de competência legal da guarda civil para

atividade de polícia e, portanto, da ilicitude da prova é o posicionamento atual da 6ª Turma do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras “polícias municipais”, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte – apesar das investidas em contrário – por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal. 2. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia civil – em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência – estão sujeitas a rígido controle correcional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais – apesar da sua relevância – não estão sujeitas a nenhum controle correcional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal. 3. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar – em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais – o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros. 4. A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para “Polícia Municipal”. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora – alguns até mesmo de porte bastante diminuto – estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas. 5. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito. 6. Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes. 7. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da

Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. 8. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas. 9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária. 10. Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito. 11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese. 12. Recurso especial provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1977119 - SP (2021/0391446-0) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ - 6ª turma - 16.08.2022).

Segundo o E.TJSP, no mesmo sentido:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova ilícita. Guarda civil não tem competência constitucional para exercício de atividade policial e, portanto, não pode por seu livre arbítrio abordar e revistar pessoas que não estejam em situação visual, crepitante e concreto de flagrante delito. Se o fizer, a prova assim produzida e toda aquela daí decorrente será ilícita, contaminando a validade da investigação daí decorrente. (TJSP - Apelação Criminal nº 1501278-74.2020.8.26.0320 - Rel. Sérgio Mazina Martins - Limeira - j. 23 de julho de 2021).

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Impetração que espera o trancamento da ação penal com base na nulidade da prova. Busca e apreensão realizada por Guardas Municipais.

Ausência de justa causa. Ordem concedida. (TJSP - Habeas Corpus n. 2016545-19.2020.8.26.0000 - 16ª Câmara - Rel. Otávio de Almeida Toledo - 04.08.2020).

No caso dos autos, tem-se que tal atuação inconstitucional do acusado, após a Guarda Civil receber denúncia, atuando esta em lugar de polícia militar ou civil traz a ilicitude de tudo o que foi amealhado aos autos, não havendo outro elemento nos autos a não ser a confissão do acusado.

Dessa forma, é certo que a confissão prestada em sede judicial não basta para sustentar a condenação do acusado.

A propósito, dispõe o art. 197, do CPP que o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para outros elementos de prova, e para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância".

Neste sentido:

ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - Quadro probatório frágil - Insuficiência de provas no tocante à associação - Condenação lastreada na confissão do réu e suspeitas de envolvimento em crimes - Crime autônomo que demanda prova do elo perene e estruturado entre os agentes para a prática da traficância - Eventual participação do réu em crimes outros aqui não apurados que não se comprovou e não faz presumir seu envolvimento na associação criminosa - Confissão judicial isolada que não tem o condão de justificar a condenação - Exegese do artigo 197 do CPP - Absolvição que se impõe - Expedição de alvará de soltura pelo processo - Recurso provido - (voto nº 44326). (TJSP; Apelação Criminal 0001501-79.2020.8.26.0586; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Roque - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/05/2021; Data de Registro: 06/05/2021)

No caso dos autos, inexistente qualquer outra prova, e mesmo a confissão do réu, como dito, advém da atuação da guarda civil metropolitana, havendo ilicitude em tudo o que foi colhido nos autos, no que se inclui a confissão do acusado.

Portanto, por conta da atuação ilegal da guarda civil, deve ser acolhido o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público.

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e ABSOLVO o réu VICTOR VIANA MATIAS, qualificado nos autos, de todas as imputações que lhe foram dirigidas, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal.

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Havendo bens ou valores apreendidos, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, fica autorizada a alienação e destinação do produto ao Funad ou Funpen, conforme o caso, a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita a sua venda, no caso de quantias em dinheiro, não havendo requerimento de levantamento no prazo de 90 dias, decreto a perda da integralidade do valor, tudo conforme disposto nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos artigos 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ.

Cautelas e comunicações de estilo.

P.I.C.

Aruja, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA